

1502288-62.2021.8.26.0048

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... alegação de que ele desconhecia a existência das armas. QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROVIDO - RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DIVERSIDADE E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA - 200 QUILOS DE MACONHA E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502288-62.2021.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502288-62.2021.8.26.0048

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERYS SOUZA DE CARVALHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

HERYS SOUZA DE CARVALHO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 02 de fevereiro de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia de Covid-19, por volta das 04h30min, na Rodovia BR 381, Km 48, posto 22, Jardim Centenário, em Atibaia, juntamente com ALEX SANDRO PEDRA, com quem agia em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, transportava duas porções de crack, pesando 1.677g e duas de cocaína, pesando 2.035g para fins de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, ALEX foi contratado, pelo valor de R\$ 1.000,00, por terceiro de alcunha "LELEU", para buscar drogas na cidade de Pouso Alegre e levá-la para Guarulhos-SP. Assim, a ré e ALEX, a cuja conduta ela aderiu, saíram da cidade de Guarulhos/SP, por volta das 21h com destino a Pouso Alegre-MG, onde se

encontraram com pessoa desconhecida e dela receberam os entorpecentes. Conforme narrou a exordial, ato contínuo, retornaram para o ponto de partida (Guarulhos), transportando as drogas, mas, antes de chegarem, pararam no mencionado autoposto. Ali, Policiais Rodoviários Federais que realizavam patrulhamento, em fiscalização e operação em postos de gasolina, a fim de acompanhar uma greve dos caminhoneiros, notaram a presença do veículo estacionado entre os caminhões e resolveram abordar os seus ocupantes. Em revista pessoal, nada de ilícito encontraram com a ré e seu comparsa, porém, no interior do veículo, os policiais acharam os entorpecentes, tendo ALEX confessado a traficância.

Nos termos da preambular, o tráfico aconteceu entre Estados da Federação. Na delegacia, HERYS negou seu envolvimento na prática delitiva, alegando que ALEX apenas a chamou para acompanhá-lo numa viagem até Pouso Alegre.

A inicial narrou que não obstante, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento dos autos nº 1500158-63.2021.8.26.0545 (nos quais ALEX está sendo processado pela prática delitiva em questão), os policiais detalharam que, quando da abordagem dos então suspeitos, a ora ré, ao ser questionada, revelou ter tomado conhecimento dos entorpecentes assim que ela e ALEX chegaram à cidade de Pouso Alegre. Isto é, a partir de então, dolosamente, aderiu à conduta delitiva, auxiliando seu asseccla no transporte das drogas.

A denúncia foi oferecida (fls. 121/123) e a ré foi notificada (fls. 166), tendo apresentado defesa preliminar (fls. 173/177), afastada por decisão que recebeu a denúncia (fls. 193/196). A ré foi citada (fls. 220). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 221/222 e 241) tendo sido, a ré, regularmente interrogada (fls. 221/222).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 242/248).

A defesa, por sua vez, entendeu não existir prova de que a ré concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que a ré não tinha conhecimento de que seu então amigo, ALEX, foi até Pouso Alegre para buscar drogas como forma de encomenda, as quais entregaria a homem de alcunha "Leleu", em Guarulhos, sendo que receberia por tal empreitada o valor de R\$ 1 mil. Asseverou que a ré desconhecia a situação, alegando que para a ré, o convite de seu amigo para acompanhá-lo até Pouso Alegre era apenas um passeio, entendendo que a acusada, em momento algum, agiu com dolo de praticar a conduta criminosa. Apontou que nenhuma substância ilícita foi encontrada com a acusada, nem dinheiro em espécie ou periféricos, razão pela qual sustentou sua absolvição pelo artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. Para o caso de condenação, requereu fixação de pena no mínimo legal, com aplicação da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, ainda, prisão domiciliar, já que a ré é mãe de cinco crianças, das quais três são menores de 12 anos de idade (fls. 252/257).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 13), no boletim de ocorrência (fls. 22/25), no auto de exibição e apreensão (fls. 26/28), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 29/30), nas fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 48/49), nos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 72/77) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada a ré que, interrogada extrajudicialmente (fls. 17), disse que estava em sua casa, em Guarulhos, quando por volta das 20h40 foi convidada por ALEX SANDRO, pessoa que conhece há cerca de cinco anos e com quem tem bom relacionamento de amizade, a ir até a cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, com a finalidade de dar um passeio; como nunca desconfiou de nada anormal com relação a ele, aceitou o convite; chegaram em Pouso Alegre por volta das 02h30, quando num bairro na zona rural, ALEX parou o veículo e um indivíduo que não pôde ver direito se aproximou a pé, sendo que ambos ficaram conversando; a pessoa passou um saco plástico para ALEX; não viu, no momento, o que tal saco continha, sendo que ALEX colocou o saco debaixo do banco do veículo; estava com bastante sono; logo em

seguida, ALEX pegou a estrada para voltar para a cidade de Guarulhos; passando por Atibaia, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, que ao fazer uma inspeção no veículo, encontrou debaixo do banco do motorista um saco plástico e, em seu interior, alguns tabletetes que veio a saber se tratar de drogas; desconhecia que ALEX havia pegado essas drogas em Pouso Alegre, mesmo porque nunca soube de nada que o desabonasse; nunca foi processada; trabalha como segurança em casas noturnas; estava fazendo "bicos", considerando a pandemia e pelo fato de sua casa estar sendo reformada; não é usuária de entorpecentes.

Em juízo, a ré disse que não conhecia o lugar, sendo que havia sido convidada para ir até lá e não sabia até então do que se tratava; foi descobrir sobre a droga quando foi detida no posto em Atibaia; indagada sobre o motivo pelo qual disse ao policial que ficou sabendo a respeito das drogas quando seu colega pegou os entorpecentes, respondeu que só ficou sabendo no momento em que foi detida, na Delegacia; não tem nada contra o policial ouvido, nem o conhece; trabalha como gerente de casa de show, aufera R\$ 1.200,00 mensais e está cursando ensino superior; nunca foi processada; conhecia ALEX SANDRO há muito tempo, tinham uma amizade de uns cinco anos; ele a chamou para acompanhá-lo numa "correria de Uber", tendo concordado em acompanhá-lo; nunca foi até aquele local e lembrou-se de ter passado por baixo de um viaduto, por um local de terra e de ter visto ALEX SANDRO conversando com um rapaz de rosto magro; indagada sobre o cheiro forte da droga no carro, respondeu que não sabia se era droga ou não, mas confirmou que seus olhos estavam ardendo muito naquele dia; indagada sobre a estranheza que envolve concordar partir numa "correria de Uber" sem sequer saber para onde estava indo, afirmou que perguntou várias vezes, mas ALEX SANDRO não lhe respondeu, sendo que o acompanhou pela amizade que tinham e não sabia que ele fazia esse tipo de coisa; indagada sobre o que aconteceu quando ALEX SANDRO chegou no destino, ou seja, em Pouso Alegre, respondeu que ele conversou com um rapaz de rosto magro, mas não conseguiu ouvir o que era, pois conversavam entre eles dois; ALEX SANDRO não desceu do carro; questionada sobre o fato de ALEX SANDRO não ter descido do carro e mesmo assim não ter ouvido o que ele conversou com o outro indivíduo, e indagada sobre não ter visto ALEX SANDRO ter recebido dois pacotes com quatro tijolos de droga, respondeu que realmente não viu, tendo afirmado que estava focando o olhar no rosto do rapaz e não o viu entregando os pacotes com drogas, pois o lugar estava muito escuro e estava tentando ouvir o que eles falavam; confrontada com a estranheza de não ter sequer reparado na movimentação, afirmou que viu a porta de trás abrir e que o local era escuro, não tinha lâmpada nenhuma; isso ocorreu por volta das dez horas, mas não se recordou ao certo; afirmou que quando foi, não sabia o que estava acontecendo, tendo sabido quando estava voltando; novamente questionada sobre em que momento ficou sabendo, relatou que ALEX SANDRO falou para o policial que estava levando drogas para Guarulhos. Tem cinco filhos e a mais nova tem quatro meses. A testemunha Renan Alves Lindoneta, policial rodoviário federal, disse que estavam em patrulhamento e adentraram um posto de gasolina, sendo que um veículo que estava estacionado saiu assim que avistou a viatura; realizaram a abordagem; havia um casal no veículo e estavam com uma história desconexa, pois cada um dizia uma coisa e estavam muito nervosos; isso gerou desconfiança na equipe, que decidiu efetuar busca no carro; encontraram no veículo tablete de drogas sob o banco do motorista; indagado sobre o tipo de droga encontrado, respondeu que, salvo engano, era crack; indagado sobre o que os indivíduos disseram durante a abordagem, explicou que a história inicial é a de que haviam voltado de uma festa num sítio; após o encontro dos entorpecentes, ambos disseram desconhecer as drogas que ali estavam; indagado pela acusação como estavam as drogas, respondeu que os dois tabletetes estavam debaixo do banco, sendo que um estava numa sacola e o outro estava solto, mexido, inclusive; questionado se estavam visíveis para os dois que estavam dentro do carro, respondeu que estavam sob o banco, sendo que até pelo cheiro da droga daria para saber; confirmou que a ré, informalmente, disse que desconhecia, primeiramente, a respeito das drogas, tendo ficado sabendo posteriormente que seu colega fazia tal entrega; indagado sobre o momento em que a ré, segundo ela própria, teria tomado conhecimento de que ia trazer drogas, respondeu que foi em Minas Gerais, somente quando chegou no local; abordaram-nos já dentro de Atibaia;

questionado se a ré confirmou que sabia a respeito das drogas no carro, respondeu que sim, afirmando ser impossível que não soubesse; indagado pela defesa se foi encontrada alguma droga com a acusada, em sua roupa, ou se alguma balança de pesagem foi encontrada no automóvel, respondeu que não.

A testemunha Renato Tadao Suda, policial rodoviário federal, disse que estavam efetuando ronda pela madrugada, sendo que passaram por um posto, o qual tinha um restaurante que estava fechado; no local havia um veículo que, ao notar a viatura, saiu; decidiram fiscalizar a situação e deram ordem de parada; havia dois ocupantes no veículo, um rapaz e uma moça, que estavam bem nervosos, alterados; em buscas no veículo, encontraram dois quilos de cocaína e um quilo e pouco de crack; indagado sobre o que a ré falou respondeu não se recordar, tendo se lembrado tão somente que eles disseram que estavam vindo de Minas Gerais, Pouso Alegre, sendo que eles estavam indo para Guarulhos; informado de que disse na Delegacia de que a ré havia dito ter tomado conhecimento de que o convite para passear com o réu ALEX não era só um passeio quando ela chegou em Pouso Alegre, sendo que ela viu o acusado em questão recebendo o entorpecente, e indagado se se recordava de ela ter narrado isso, respondeu acreditar que foi isso mesmo; indagado se quando é ouvido na Delegacia, com os fatos frescos na memória, costuma dizer tudo o que sabe e a verdade, respondeu que sim; questionado se confirmava, em juízo, que o que disse em solo policial na ocasião era verdade, respondeu que sim.

Eis a prova oral colhida.

A ré negou a prática do delito, afirmando, em solo policial, que foi convidada por ALEX SANDRO a ir até Pouso Alegre para dar um passeio, sendo que chegaram em tal cidade por volta das 02h30. Afirmou que ALEX parou o carro num bairro em zona rural, onde um indivíduo que não conseguiu enxergar direito se aproximou e passou a conversar com ALEX, entregando a ele um saco plástico.

A ré disse que não viu o que havia em tal saco, o qual ALEX colocou sob o banco. Disse que estava com bastante sono e quando voltavam, ao passar por Atibaia, foram abordados.

Alegou não saber que ALEX havia pegado drogas em Pouso Alegre.

Em juízo, a ré voltou a negar a prática delitiva, trazendo pequenas - mas importantes - alterações, entretanto, em sua narrativa.

Afirmou, inicialmente que foi descobrir sobre as drogas quando foi detida no posto em Atibaia, mas ao final de seu depoimento, disse que quando foi, não sabia o que estava acontecendo, tendo sabido quando estava voltando. Ao dizer isso, foi novamente indagada sobre o momento em que ficou sabendo sobre os entorpecentes que eram transportados no veículo, tendo desconversado, alegando que ALEX SANDRO falou para o policial que estava levando drogas para Guarulhos.

Sobre a dinâmica da ocorrência, alegou que ALEX SANDRO a chamou para acompanhá-lo numa "correria de Uber", tendo concordado em acompanhá-lo. Confirmou ter visto ALEX SANDRO conversando com um rapaz de rosto magro num local de terra e ao ser questionada sobre o cheiro forte de entorpecente dentro do carro, respondeu que não sabia se era droga ou não, afirmando que seus olhos estavam ardendo muito naquele dia.

A ré ainda negou ter ouvido a conversa entre ALEX SANDRO e o rapaz, mesmo afirmando que ALEX SANDRO não desceu do carro, dizendo que estava focando o olhar no rosto do rapaz e não o viu entregando os pacotes de drogas, pois o lugar estava muito escuro e ficou tentando ouvir o que eles diziam.

Sua lânguida narrativa, além de contar com severas incoerências - como não ter ouvido o diálogo entre ALEX SANDRO e o rapaz que fez a entrega dos entorpecentes, mesmo estando dentro do mesmo carro em que ALEX SANDRO estava, ou sobre ter dito, ao final de seu interrogatório, que ficou sabendo o que estava acontecendo quando estava voltando, desconversando ao ser novamente indagada sobre o momento em que tomou conhecimento a respeito das drogas dentro do carro - foi absolutamente infirmada pelo seguro relato dos agentes policiais ouvidos.

O policial Renan relatou que durante patrulhamento, adentraram um posto de gasolina, sendo que um veículo que estava estacionado saiu ao perceber a viatura, razão pela qual tal veículo foi abordado.

A testemunha disse ter encontrado um casal no carro e que apresentaram relato

desconexo, cada um dizendo uma coisa. Ambos aparentaram muito nervosismo.

O agente relatou que em busca realizada no veículo, encontraram dois tabletes de drogas sob o banco do motorista, um dentro de uma sacola e outro solto e mexido. O agente ainda relatou que o cheiro do entorpecente era perceptível no automóvel. Ao ser questionado sobre o momento em que a ré afirmou ter tomado conhecimento a respeito das drogas que transportaria, respondeu que foi em Minas Gerais, ou seja, somente quando chegou ao local no outro Estado. E questionado se a ré sabia sobre os entorpecentes no automóvel, respondeu que sim, alegando ser impossível que não soubesse.

De teor semelhante, o relato da testemunha Renato, a qual confirmou que durante ronda pela madrugada, ao passaram por um posto, um veículo, ao perceber a presença da viatura, saiu.

O agente relatou que decidiram efetuar a abordagem do carro e que os dois ocupantes do veículo, um rapaz e uma moça, estavam bem nervosos.

Renato confirmou que em buscas no veículo, encontraram dois quilos de cocaína e um quilo e pouco de crack.

O policial não se recordou sobre o que a ré disse ao ser questionada sobre os entorpecentes, mas ao ser confrontado com seu depoimento prestado em solo policial, confirmou que o que disse em solo policial era verdade, ou seja, que a acusada teria tomado conhecimento de que o convite para passear com ALEX não era só um passeio quando chegou em Pouso Alegre, ocasião em que viu seu comparsa recebendo entorpecentes.

Como se observa, ambos os agentes policiais confirmaram que a acusada disse, no momento da abordagem, ter tomado conhecimento de que transportaria drogas juntamente com ALEX ainda em Pouso Alegre, ocasião em que referido indivíduo recebeu, de terceira pessoa, grande quantidade de entorpecentes em tabletes.

Mesmo sabedora de que o carro tinha entorpecentes, a ré permaneceu no veículo e voltou de Pouso Alegre em companhia de ALEX. É evidente que a acusada anuiu à empreitada levada à efeito por referido indivíduo, sendo certo que conforme afirmou o agente Renan, era impossível que a ré não soubesse a respeito das drogas, até porque o cheiro dentro do veículo, de acordo com o depoimento de tal policial, era perceptível.

Não obstante, ambos os policiais confirmaram que ao iniciar a abordagem, os dois ocupantes do veículo demonstraram nervosismo. Ora, se a ré nada sabia a respeito das drogas que transportava, por qual motivo demonstraria nervosismo?

Por óbvio, HERYS tinha completo conhecimento de que vinha de Pouso Alegre, com destino a Guarulhos, transportando grande quantidade de entorpecentes, sendo certo que sua narrativa de que nada sabia até o momento da abordagem não restou minimamente comprovada, não havendo motivos para se crer que os agentes policiais, que sequer a conheciam anteriormente, imputar-lhe-iam falsamente depoimento, somente com a finalidade de incriminá-la.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão da ré.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não conheciam a ré e que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior na sua gratuita acusação.

Sobre as drogas apreendidas, é curial destacar que os exames periciais identificaram a apreensão de substâncias que acusaram teste positivo para cocaína (fls. 72/77), sendo certo que o crack é produzido a partir dos restos do refino da cocaína, que, por sua vez, é produzida a partir de uma pasta-base. O crack, portanto, não é substância autônoma, mas sim subproduto da cocaína. Logo, é certo que o laudo de exame químico-toxicológico, ao analisar o crack, atestará a presença de cocaína.

Restou evidenciado, portanto, que ocorrência se amoldou com perfeição no artigo pelo qual a ré foi denunciada, uma vez que o artigo 33 da Lei 11.343/06 não define como necessário, para a consumação das figuras típicas em questão, o caráter comercial do tráfico. Aliás, sequer delimita qualquer definição para "traficante", limitando-se a descrever figuras típicas que, praticadas, ensejam determinada penalidade.

In verbis:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa" (Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006).

Optei por destacar, na transcrição acima, justamente a conduta descrita na denúncia, a qual foi perpetrada pela ré, que juntamente com ALEX, transportava drogas (das quais tinha completo conhecimento, conforme já analisado), bem como o restante do dispositivo, restando evidenciado que não há, na Lei, qualquer menção à finalidade mercantil da droga.

Além disto, o tráfico interestadual, previsto no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, se mostrou plenamente caracterizado.

No caso dos autos, a ré, juntamente com seu comparsa, já havia cruzado a fronteira do Estado de Minas Gerais, tendo chegado em Atibaia, onde foi flagrada com enorme quantidade de entorpecentes.

Em caso semelhante ao ora sentenciado, já se decidiu:

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 - TRÁFICO INTERESTADUAL - TRANSPORTE QUE NÃO ULTRAPASSOU A FRONTEIRA ENTRE DOIS ESTADOS - IRRELEVÂNCIA - DROGA QUE TINHA COMO DESTINO OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Para incidência da causa especial de aumento do tráfico interestadual basta que esteja comprovado que o produto tóxico tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual. Incide a causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, se o veículo apreendido com a droga tinha placa do Estado de destino e o recorrente em juízo

confessa que a droga transportada ia ser entregue no Estado de Goiás. EMENTA DO RECURSO DE CARLOS ALBERTO: QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO: PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA DOS TRAFICANTES E LEVAVA ARMAS DE USO RESTRITO JUNTO COM A CARGA DE COCAÍNA - RECURSO IMPROVIDO. Se as drogas foram acondicionadas no mesmo fundo falso no qual foram encontradas as armas, e estando o acusado ciente da existência da droga, incabível a alegação de que ele desconhecia a existência das armas. QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROVIDO - RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DIVERSIDADE E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA - 200 QUILOS DE MACONHA E HAXIXE E 03 QUILOS DE COCAÍNA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - INAPLICABILIDADE DA REDUTORA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - SOMATÓRIO DAS PENAS DE TRÁFICO E PORTE DE ARMA QUE TOTALIZAM MAIS DE 08 ANOS - OBRIGATORIEDADE DO REGIME FECHADO NOS TERMOS DA ALÍNEA A DO § 2º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a circunstância negativa acerca das consequências do crime não está amparada por um elemento concreto que justifique a elevação da pena acima do mínimo, deve a pena ser um pouco reduzida pela retirada desta circunstância. Não se aplica a redutora do tráfico privilegiado àquele que, apesar de primário, traficava elevada quantidade e diversidade de drogas, demonstrando que não se trata de um mero "mula", mas de pessoa dedicada ao tráfico de drogas. Se o somatório das penas dos crimes de tráfico e porte de arma totaliza mais de 08 anos, deve o regime de cumprimento de pena se iniciar no fechado, nos termos da alínea A do § 2º do art. 33 do CP" (APL TJ/MS 0006466-46.2013.8.12.0001; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; Publicação: 27/03/2014; Julgamento: 24 de Fevereiro de 2014; Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha) (destaquei).

Assim, a prova é coesa e suficiente para a condenação, considerando que a ré anuiu dolosamente à conduta do acusado ao tomar conhecimento de que transportavam entorpecentes no veículo, o que ocorreu em Pouso Alegre, conforme narraram os policiais ouvidos - e a própria acusada, em aparente ato falho no final de seu interrogatório, quando afirmou ter ficado sabendo dos entorpecentes no veículo quando estava voltando - não havendo como acolher a alegação defensiva de que a ré não concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas.

A condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Ré primária, que não ostenta antecedentes (fls. 140). Culpabilidade normal à espécie. Pouco se colheu sobre sua conduta social e personalidade. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de alterar a pena-base. Quanto à natureza e quantidade do produto, foram apreendidos um tijolo com massa líquida de 1.963 gramas e outro tijolo com massa líquida de 1.615,5 gramas, tratando-se de cocaína e crack.

O crack é um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários. A alta taxa de mortalidade entre os consumidores e o absurdo poder viciante do entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua comercialização, exemplarmente repreendida (artigo 42, Lei 11.343/06). Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde

pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Assim, com base no exposto nesta primeira fase da dosimetria, considerando os tipos de entorpecentes transportados, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, diária mínima, considerada a renda afirmada pela acusada. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não incidem agravantes ou atenuantes.

Não é o caso de reconhecimento da agravante do art. 61, II, j, do CP.

Mudando entendimento anterior, verifico que o estado de calamidade cessou a partir de 01/01/2021. Isto porque o Decreto Legislativo nº 06, de 2020, tinha vigência até 31/12/2020.

E embora o Governo tenha editado inúmeros decretos relativos à pandemia COVID-19, que somente foram revogados em maio de 2022, pelo Decreto 11.077 de 20/05/2022, certo é que não houve prorrogação do estado de calamidade, mas tão somente decretação de estado de emergência, que foi encerrado em abril de 2022, conforme pronunciamento do Ministro Queiroga, em rede nacional, em 17/04/2022.

Assim, afasto a agravante pleiteada.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, fez-se presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V. A ré transportava, em comparsaria, entorpecentes de Pouso Alegre para Guarulhos, tendo sido flagrada em Atibaia, momento em que o tráfico entre Estados da Federação já havia se consumado.

A pena é aumentada em 1/6, atingindo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Não entendo cabível a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. A ré, embora primária, transportava em comparsaria enorme quantidade de crack e cocaína, não havendo como assumir que a conduta perpetrada não esteja intimamente relacionada com a dedicação à atividade criminosa.

Grandes quantidades de entorpecente já fundamentaram o afastamento da benesse em questão, conforme se observa do decisum ora transcrito:

“Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas.

Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Atenuação da pena pela

confissão. Impossibilidade. Aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da

Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Quantidade de droga apreendida incompatível com

a concessão do benefício. Sanção penal mantida. Não provimento ao recurso.” (TJ-SP

- APL 00004065720138260651; Relator: Zorzi Rocha; Julgamento: 09/10/2014; Órgão

Julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 13/10/2014).

A pena definitiva para este delito fica mantida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Considerando o montante de pena aplicado e o tipo do crime sob análise, a ré iniciará o cumprimento da pena referente aos crimes punidos com reclusão em regime fechado.

Como é sabido, o tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.



Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir,

data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados quaisquer benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar HERYS SOUZA DE CARVALHO, como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 680 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

A ré respondeu ao processo em liberdade e, não havendo alteração fática apta a

ensejar mudança de sua atual situação, poderá oferecer recurso, se assim desejar, em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, expedindo-se, oportunamente, o competente mandado de prisão em regime fechado.

Condene a ré ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P.I. e C.

Atibaia, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA